

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 857/2536 พนักงานอัยการ จังหวัด พิษณุโลก โจทก์
นาย เสี่ยงม อินทะ แสน จำเลย

ป.อ. มาตรา 63, มาตรา 80, มาตรา 91, มาตรา 277 วรรคสอง, มาตรา 277 ทวิ,
มาตรา 297

ป.วิ.อ. มาตรา 158, มาตรา 192

ผู้เสียหายเป็นเด็กหญิงอายุ 8 ปี จำเลยใช้อวัยวะเพศของจำเลยใส่ไปที่ช่องขา
ใกล้อวัยวะเพศของผู้เสียหาย และได้กระทำการในลักษณะของการกระทำชำเรา ที่
บริเวณรูทวารหนักของผู้เสียหายมีรอยชำแดงและที่ระหว่างช่องคลอดกับรูทวารหนัก
มีรอยถลอกเล็กน้อย อวัยวะเพศของจำเลยไม่ได้เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหาย
คงอยู่บริเวณปากช่องคลอดของผู้เสียหายเท่านั้น ดังนั้น การกระทำของจำเลยจึงเป็น
เพียงความผิดฐานพยายามกระทำชำเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกิน 13 ปี ทางพิจารณาไม่
ปรากฏว่าการที่ผู้เสียหายขัดขืนไม่ยอมให้กระทำชำเรา จำเลยได้ชกต่อยและตบปาก
ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บอย่างไรคงได้ความว่าหลังจากจำเลยกระทำชำเราและจำเลย
กับผู้เสียหายสวมใส่เสื้อผ้าแล้ว จำเลยได้ต่อยเตะจนผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส
การกระทำของจำเลยดังกล่าวมิได้กระทำต่อเนื่องกัน หากแต่ขาดตอนจากการกระทำ
ชำเราแล้ว ดังนี้ แม้ผู้เสียหายจะได้รับอันตรายสาหัสก็มีผลโดยตรงจากการกระทำ
ชำเราอันจะเป็นเหตุให้ผู้กระทำจะต้องได้รับโทษหนักขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 277 ทวิ โจทก์บรรยายฟ้องเพียงว่าจำเลยกระทำผิดฐานกระทำชำเราผู้เสีย
หายเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 277, 277 ทวิ, และ 297 แม้โจทก์จะอ้างมาตรา 297 มาด้วย แต่โจทก์

มิได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดหลายกรรมจึงไม่ชัดเจนว่าโจทก์ประสงค์ให้
ลงโทษจำเลยฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ไม่อาจ
ลงโทษจำเลยฐานดังกล่าวได้เพราะเป็นการนอกเหนือจากฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำชำเราเด็กหญิงสุรินทร์ สืบประยูรอายุ 8 ปี ผู้เสีย
หายจนสำเร็จความใคร่ 1 ครั้ง โดยผู้เสียหายไม่ยินยอมและอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถ
ขัดขืนได้โดยจำเลยใช้มือทุบต้นขาใช้เท้าเตะขาผู้เสียหายล้มลงศีรษะกระแทกพื้น
อย่างแรง เป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส ขอให้ลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 277, 277 ทวิ, 297

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 277 วรรคสอง, 277 ทวิ(1), 297 ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 277 วรรคสอง ประกอบมาตรา 277 ทวิ(1)ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 15 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยใช้อวัยวะเพศของจำเลยใส่ไปที่ช่องขาไถ่
อวัยวะเพศของผู้เสียหายและได้กระทำการในลักษณะของการกระทำชำเรา ที่บริเวณ
รูดวารหนักจึงมีรอยชำแดงและที่ระหว่างช่องคลอดกับรูดวารหนักมีรอยถลอกเล็ก

น้อย การกระทำของจำเลยดังกล่าวถือได้ว่าจำเลยได้ลงมือกระทำชำเราผู้เสียหายแล้ว แต่อวัยวะเพศของจำเลยไม่ได้เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายคงอยู่บริเวณปากช่องคลอดของผู้เสียหายเท่านั้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นเพียงความผิดฐานพยายามกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 13 ปี และทางพิจารณาไม่ปรากฏว่าการที่ผู้เสียหายขัดขืนไม่ยอมให้กระทำชำเราจำเลยได้ชกต่อยและตบปากผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บอย่างไร คงได้ความว่าหลังจากจำเลยกระทำชำเราและจำเลยกับผู้เสียหายสวมใส่เสื้อผ้าแล้วจำเลยได้ต้อยเตะจนผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส การกระทำของจำเลยดังกล่าวมิได้กระทำต่อเนื่องกันหากแต่ขาดตอนจากการกระทำชำเราแล้วดังนี้ แม้ผู้เสียหายจะได้รับอันตรายสาหัสก็มีใช้ผลโดยตรงจากการข่มขืนกระทำชำเราอันจะเป็นเหตุให้ผู้กระทำจะต้องได้รับโทษหนักขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 ทวิ จึงไม่อาจลงโทษจำเลยตามบทดังกล่าวได้ ส่วนความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนั้น แม้โจทก์จะอ้างมาตรา 297 มาด้วย แต่ฟ้องโจทก์มิได้บรรยายว่า กระทำผิดก่กรรมและเมื่อใดบ้าง ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าโจทก์ประสงค์จะให้ลงโทษจำเลยก่กรรม คำฟ้องของโจทก์ไม่ชัดเจนว่าโจทก์ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส จึงไม่อาจลงโทษจำเลยฐานดังกล่าวนี้ได้เพราะเป็นการนอกเหนือจากฟ้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 80 จำคุก 10 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(สมาน เวทวินิจ-ปรีชา ธนानันท์-จิระ บุญพจนสุนทร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ